Tribunal de Justiça de Pernambuco
Poder Judiciário
Vara Única da Comarca de Mirandiba

R JOSEFA MAGALHÃES, S/N, FORUM ALCINDO TORRES DE CARVALHO LOPES, Centro, MIRANDIBA - PE - CEP: 56980-000 - F:(87) 38851921

Processo nº 0000826-52.2023.8.17.2950

AUTOR(A): PROMOTOR DE JUSTIÇA DE MIRANDIBA

RÉU: MUNICIPIO DE MIRANDIBA, MARIA DO SOCORRO GOMES DE SA

SENTENÇA

I - RELATÓRIO

O Ministério Público de Pernambuco, na qualidade de substituto processual de José Matheus Gonçalves Valões, nascido em 17.09.2022, nos autos representada por Jéssica Maria Gonçalves Gomes, natural de Serra Talhada /PE, residente na Rua Antônio Gomes de Sá, bairro do Centro, Mirandiba/PE, ajuizou a presente ação civil pública em face do MUNICÍPIO DE MIRANDIBA/PE e OUTROS, com o fito de obrigar o ente a fornecer alimento especial para a criança cuja família não dispõe de recursos para arcar.

A inicial foi instruída com documentos com documentos com o fim de comprovar o alegado, faço destaque ao documento lavrado pelo médico **Murilo L Pereira, CRM-PE 33647**, que informa a necessidade do **alimento especial em virtude de diagnóstico prévio de intolerância, sem aceitação de outras fórmulas mais baratas (ID 147568732)**.

Em sede de análise precária dos autos, determinei a antecipação dos efeitos da tutela pretendida no ID 147740732, nos seguintes termos:

> "Ante ao exposto, e por tudo mais que dos autos constam, com base nos fundamentos acima explicitados, **CONCEDO** a **MEDIDA DE URGÊNCIA PLEITEADA** na exordial para determinar que o **MUNICÍPIO DE MIRANDIBA**, providencie, sob pena de

multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), em face do Município de Mirandiba, com teto de R$ 10.000,00, bem como da ordenadora de despesas da pasta, estabelecido o teto de R$ 5000,00, no prazo de cinco (cinco) dias, o fornecimento de: suplemento alimentar Aptamil ProExpert SL, na quantidade de 08 (oito) latas (de 800g) mensais, pelo período mínimo de 5 (cinco) meses, até a reavaliação em retorno ambulatorial"

NO ID 148487472 há petição da parte requerida comprovando o cumprimento da decisão.

Aportou aos autos a contestação ID 148493847, em que o objeto da lide não foi contestado, apenas o fato de o Município estar isolado no polo passivo, quando, em seu sentir, deveria o povo passivo estar composto pelo, também, pelo Estado de Pernambuco.

O Ministério Público acostou réplica no ID 157605488, sustentando a presença das razões constantes na inicial, com o julgamento pela procedência do feito e, ainda, que, no caso de este Togado considerar a necessidade de adequação do polo passivo, isso pode se dar em sede de ação posterior em que o Município poderia vindicar o ressarcimento de valores.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário. **FUNDAMENTO** e **DECIDO.**

II - FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de *ação ordinária* para fornecimento do suplemento alimentar, em virtude de a favorecida ser portadora de enfermidade relacionada à proteína do leite, o que torna imprescindível determinados alimentos que a parte autora não possui condições de arcar.

Pois bem, o direito à saúde, como um direito subjetivo fundamental básico a todo cidadão brasileiro, deve ser providenciado por todos os entes federativos, sendo de responsabilidade solidária da União, dos Estados e dos Municípios.

Com efeito, em razão do caráter solidário da obrigação de prestação de serviços públicos de saúde (na qual se inclui, induvidosamente, o fornecimento de suplementos alimentares essenciais à população carente), podem **ser demandados quaisquer dos devedores coobrigados, à escolha do credor.**

Nesse sentido, o Colendo Supremo Tribunal Federal, no Recurso Extraordinário 855.178/SE, submetido ao regime da repercussão geral, assim decidiu:

EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA.

O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. **O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente**.

(RE 855.178 RG/SE, Relator(a): Min. Luiz Fux, julgado em 05/03/2015, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe - 050 DIVULGADO EM 13-03-2015 E PUBLICADO EM 16-03-2015). - Destaques nossos.

Ademais, a jurisprudência é ampla e pacífica nesse sentido, como se extrai do verbete sumular nº 130 do E. TJPE, que trata especificamente de medicamento, porém, é aplicável ao presente caso, *por analogia*:

A ação para o fornecimento de medicamentos e afins pode ser proposta, indistintamente, em face da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.

O cerne da presente demanda está em verificar se o **MUNICÍPIO DE MIRANDIBA** deve ser compelido a fornecer à autora o suplemento alimentar, nas proporções e pelos períodos requeridos.

Sem maiores delongas, registro, desde logo, que o pedido formulado na exordial deve ser julgado **PROCEDENTE.**

A CRFB, em seu art. 6º, estabelece que:

São direitos sociais a educação, a saúde, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Por sua vez, o art. 196 da Carta Magna define que:

A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Conforme se depreende dos preceitos constitucionais suso transcritos, compete ao Poder Público garantir e assegurar o direito à saúde, que é indissociável do direito à vida, prerrogativa constitucional com caráter de direito fundamental, que não pode ser preterido por questões burocráticas, políticas, econômicas ou orçamentárias.

Neste passo, já afirmou o Ministro Marco Aurélio que "*O Estado deve assumir as funções que lhe são próprias, sendo certo, ainda, que problemas orçamentários não podem obstaculizar o implemento do que previsto constitucionalmente*"[2] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftn2).

No expressivo dizer de José Afonso da Silva, "*o sistema único de saúde, integrado de uma rede regionalizada e hierarquizada de ações e serviços de saúde, constitui o meio pelo qual o Poder Público cumpre seu dever na relação jurídica de saúde que tem no polo ativo qualquer pessoa e a comunidade, já que o direito à promoção e à proteção da saúde é também um direito coletivo. O sistema único de saúde implica ações e serviços federais, estaduais, distritais (DF) e municipais, regendo-se pelos princípios da descentralização, com direção única em cada esfera de governo, do atendimento integral, com prioridade para as atividades preventivas, e da participação da comunidade, que confirma seu caráter de direito social pessoal, de um lado, e de direito social coletivo, de outro*"[3] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftn3).

Nessa esteira de raciocínio, assim decidiu o E. Supremo Tribunal Federal: "*O direito à saúde – além de qualificar-se como direito fundamental que assiste a todas as pessoas – representa consequência constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável omissão, em grave comportamento inconstitucional. A interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente. O caráter programático da regra inscrita no art. 196 da Carta Política – que tem por destinatários todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a organização federativa do Estado brasileiro – não pode converter-se em promessa constitucional inconsequente, sob pena de o Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado*"[4] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftn4).

Conclui-se, pois, que a garantia constitucional e/ou direito à saúde e os meios necessários para a efetivação do princípio da dignidade da pessoa humana não significam tão somente um "sonho" do legislador constituinte embebido em devaneio altruísta.

A moderna hermenêutica constitucional aponta para a máxima eficácia das normas, mesmo em se tratando de normas programáticas, sendo que no caso se depara com normas imediatamente preceptivas, dado o grau imediato de comando e eficácia.

Assim, seja com base nos preceptivos constitucionais elencados, de eficácia não programática, mas autoexecutáveis, seja com base na legislação infraconstitucional, o direito invocado está garantido na *Lex Mater*, e deve ser efetivado mediante a obrigação dos Municípios e do Estado de arcar com despesas referentes ao fornecimento de medicamentos e insumos, devidamente prescritos, aos cidadãos sujeitos a tratamento médico específico, ademais, por garantirem o direito à vida.

Nesse passo, o fato de alguém necessitar de tratamento inadiável, aliado ao impostergável dever do Estado de assegurar a todos os cidadãos, especialmente aos mais carentes, o direito à saúde, justifica a imposição ao ente público da obrigação de disponibilizar os meios necessários ao tratamento adequado ao caso, fornecendo-lhes, sobretudo em casos como o figurado em tela, o que for imprescindível para garantir-lhes melhor qualidade de vida, diminuindo os sofrimentos de que padecem.

No caso *sub examine,* trata-se de paciente portadora de ***enfermidade decorrente ALERGIA ALIMENTAR***, à qual foi indicado o uso do suplemento alimentar Aptamil ProExpert SL, na quantidade de 08 (oito) latas (de 800g) mensais, pelo período mínimo de 5 (cinco) meses, até a reavaliação em retorno ambulatorial, conforme prescrição médica acostada .

A imprescindibilidade do suplemento alimentar solicitado restou evidenciada pela apreciação do documento lavrado pelo médico **Murilo L Pereira**, **CRM-PE 33647**, que informa a necessidade do **alimento especial em virtude de diagnóstico prévio de intolerância**, **sem aceitação de outras fórmulas mais baratas (ID 147568732)**.

Não há como se argumentar no sentido de não constar das listagens oficiais de dispensação gratuita pelo SUS, **pois que todos têm o direito a receber as medicações que sejam mais adequadas às suas respectivas condições de saúde e que possam ser mais eficazes no combate a doenças** (TJ-PE - AGV:

4105020 PE, Relator: Rafael Machado da Cunha Cavalcanti, Data de Julgamento: 10/06/2016, 4ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 07/07/2016).

Assim, é patente a gravidade da doença que aflige o paciente **José Matheus Gonçalves Valões**, atestada pela documentação acostada aos autos, tendo-se em vista sua condição de saúde, comprovada por meio de laudo médico lavrado por **Murilo L Pereira**, que compromete seu desenvolvimento pleno.

Especificamente sobre a obrigação de fornecimento do *suplemento alimentar*, em julgados assim decidiu o E. TJPE:

> **EMENTA:** DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO REEXAME. NECESSÁRIO E APELAÇÃO CÍVEL. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. INEXISTÊNCIA DE ATO ILEGAL OU PRATICADO COM ABUSO DE PODER. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INCERTEZA DO DIREITO À ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM DO MUNICÍPIO. PRELIMINARES REJEITADAS. **FORNECIMENTO GRATUITO DA FÓRMULA INFANTIL NEOCATE LCP**. POSTERIORMENTE MODIFICADO PARA NEOCAT ADVANCE. **PACIENTE PORTADORA DE ALERGIA À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA. RESPONSABILIDADE DO PODER PÚBLICO**. DECISÃO FULCRADA NA CF/88, SÚMULA 18 DESTA CORTE E JURISPRUDÊNCIA DOS TRIBUNAIS. REEXAME NECESSÁRIO IMPROVIDO. PREJUDICADO O APELO VOLUNTÁRIO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Rejeitam-se as preliminares de ilegitimidade passiva ad causam pela edilidade, de falta de interesse de agir, inexistência de ato ilegal ou praticado com abuso de poder, uma vez que é justamente em razão do caráter solidário da obrigação de prestação de serviços públicos de saúde (na qual se inclui o fornecimento de compostos alimentícios/tratamentos essenciais à população carente) que podem ser demandados quaisquer dos devedores co-obrigados. **Assente entendimento jurisprudencial, o pleito da exordial visa dar efetividade ao direito constitucional à saúde e à vida. O Estado, em todas as esferas, tem o dever de assegurar às crianças e adolescentes, com absoluta prioridade, o direito à vida e à saúde, com arrimo no artigo 196 do Constituição Federal de 1988. Cabe ainda observar que, atendendo ao preceituado no art. 198, da CF/88, a Lei nº. 8.080/90, que tratou da organização do SUS (Sistema Único de Saúde), determinou, mais especificamente nos seus arts. 4º e 7º, XI, a conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na**

prestação de assistência à saúde da população. 2. Imprescindibilidade da fórmula infantil solicitada resta evidenciada. Médica especialista em alergologia, atesta no documento de fls.14, não só a enfermidade da qual a parte impetrante/apelada, ainda lactente, é portadora mas, também, o seu histórico negativo na utilização de outras fórmulas infantis, dificuldade de ganho de peso, com os quais não obteve sucesso, sobrevindo a consequente indicação da fórmula infantil especial (leite) NEOCATE LCP, conforme relatório Médico firmado pela Dra. Patrícia Aragão, CRM-PE nº 19090, fls. 14, modificado para NEOCAT ADVANCE pelo Laudo de Terapia Nutricional, o que se pressupõe a sua efetiva adequação à enfermidade da impetrante diante do seu histórico quadro clínico pessoal. **3. Patente a gravidade da doença que aflige a menor lactente, pelo que o atendimento ao referido pleito na forma já deferida é indispensável à efetividade aos direitos à saúde, à vida e à dignidade da pessoa humana, assegurados nos art. 5º e 196 da Constituição Federal. 4. Não se trata de prestação jurisdicional invasiva da seara administrativa, eis que a ordem deferida em primeiro grau apenas determina o cumprimento de obrigação já adrede imposta pela própria Constituição da República**. 5. Reexame necessário improvido, prejudicado o apelo voluntário. (TJ-PE - Apelação/Remessa Necessária 517297-4 - 0007615-42.2016.8.17.1130, 1ª Câmara de Direito Público, Relator: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 12/03/2019, Data de Publicação: 22/03/2019). - Destaques nossos.

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. **PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA E DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO. REJEITADAS.** MANDADO DE SEGURANÇA. **FORNECIMENTO DE FÓRMULA DE AMINOÁCIDOS (NEOCATE) A RECÉM NASCIDO ALÉRGICO À PROTEÍNA DO LEITE DE VACA.** SEM CONDIÇÕES FINANCEIRAS PARA ARCAR COM A PRESCRIÇÃO MÉDICA. PRESERVAÇÃO DO DIREITO À VIDA E À SAÚDE. DEVER DO ESTADO. ASTREINTES FIXADAS DENTRO DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. MATÉRIA NÃO AFETA AO JULGAMENTO DO RESP 1.657.156 DO STJ. SEGURANÇA CONCEDIDA. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DECISÃO UNÂNIME. 1. [...]. 2. O impetrado alega, ainda, a ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO em relação ao suplemento alimentar NEOCATE, por ser

responsabilidade do Município. Contudo, a jurisprudência do STJ firmou-se no sentido da responsabilidade solidária da União, Estados e Municípios nas ações onde se postula fornecimento público de medicamentos/insumos e/ou tratamento médico, sendo que a solidariedade não induz litisconsórcio passivo necessário, mas facultativo, cabendo à parte autora a escolha daquele contra quem deseja litigar, sem obrigatoriedade de inclusão dos demais. Preliminar que também não merece acolhimento. 3. Mérito. 4. Extrai-se do laudo médico (fls. 12/13) ser a criança impetrante portadora de **alergia à proteína do leite de vaca** (CID-10 T78.4) e **seletividade alimentar**. Sendo necessário que se mantenha em uso de fórmula de aminoácidos (nome comercial NEOCATE), na quantidade de 12 (doze) latas mensais, até completar 24 (vinte e quatro) meses de vida, no momento estando apenas com 15 (quinze) meses. 5. O insumo acima mencionado mostra-se indispensável ao tratamento da enfermidade e resguardo da vida do paciente. O fato de alguém necessitar de tratamento essencial, aliado ao impostergável dever comum da União, Estados e Municípios em assegurar a todos o direito à saúde, justifica a imposição da obrigação de disponibilizar os meios necessários e adequados ao caso. 6. É necessário que o Estado disponibilize as medidas necessárias para garantir aos seus cidadãos melhor qualidade de vida, minimizando os sofrimentos da doença, em observância aos ditames constitucionais da Dignidade da Pessoa Humana. 6. O entendimento do STJ e deste Sodalício é a de ocorrência de violação ao direito fundamental de acesso universal e igualitário à saúde, quando da negativa pelo ente público de fornecimento de medicamentos e procedimentos urgentes. 7. Ante a garantia à saúde e à vida, ampla e irrestrita, não cabe ao Estado obstaculizar ou mesmo impedir o tratamento adequado ao paciente, mesmo sob o argumento de falta em estoque, cabendo a ele buscar maneiras de disponibilizar os fármacos para suprir as carências sociais. 8. **Ao reverso do arrazoado no presente recurso, inexistir qualquer vulneração ao art. 2º da CF, pois o togado singular não adentra no mérito administrativo, sua conduta é direcionada à observância da legalidade, porquanto a saúde é um direito garantido a todos, conforme disposto no art. 196 da Carta Magna.** 8. Quanto às astreintes, entendo que a fixação no patamar de R$ 1.000,00 (um mil reais) por dia de

descumprimento está em consonância com os parâmetros utilizados por este Sodalício, assim como atende aos Princípios da Razoabilidade e Proporcionalidade. [...]. 10. Segurança concedida à unanimidade, confirmando a liminar (fls. 30/32), para determinar ao Estado de Pernambuco o custeio da fórmula de aminoácidos (nome comercial: NEOCATE), na forma recomendada às fls. 12/13, sendo necessário à criança fazer uso de 12 (doze) latas mensais, condicionada a permanência da disponibilidade do insumo à apresentação de receita médica a cada 6 (seis) meses. Agravo Interno (fls. 37/43v.) prejudicado. (TJ-PE - Mandado de Segurança Cível 491988-8 - 0005176-19.2017.8.17.0000, Seção de Direito Público, Relator: Itamar Pereira da Silva Junior, Data de Julgamento: 16/05/2018, Data de Publicação: 05/06/2018). - Destaques nossos.

EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. PACIENTE COM HISTÓRIA CLÍNICA DE EPISÓDIOS PROBLEMÁTICOS NO SISTEMA DIGESTIVO. **MEDICAMENTO. FÓRMULA NEOCATE.** PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REJEIÇÃO. NO MÉRITO, SEGURANÇA CONCEDIDA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 18 DO TJPE. ASTREINTES. POSSIBILIDADE. DECISÃO UNÂNIME. AGRAVO REGIMENTAL PREJUDICADO. 1. **Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, objetivando decisão judicial que determine o fornecimento de NEOCATE, em favor da impetrante, que, por sua representante, argumenta ser portadora de alergia à proteína de leite da vaca**, conforme atestado médico subscrito às fl. 18. [...]. **7. Foi levantada a preliminar de ilegitimidade passiva da autoridade coatora, sob o argumento de que existe Política Nacional de Alimentação e Nutrição nos Municípios, os quais recebem repasses de verbas do Ministério da Saúde, nos termos da Portaria MS nº 2.685/2011. A preliminar suscitada não merece ser acolhida, senão vejamos. É dever do Poder Público fornecer o medicamento do qual necessita o paciente seja por qualquer dos entes da federação, tendo em conta o que preceitua o art. 23, II e do art. 197, ambos da Constituição Federal, no caso, a responsabilidade é solidária.** [...]. 8. No mérito, tem-se que o Sistema de Saúde pressupõe uma assistência integral, no plano singular ou coletivo, na conformidade das necessidades de cada

paciente, independente da espécie e nível de enfermidade, razão pela qual, comprovada a necessidade do medicamento para a garantia da vida, deverá ele ser fornecido. - Nesse fim, a concessão da segurança tem por escopo tornar efetiva as previsões constitucionais, dispostas nos arts. 196 da Carta de 1988 e 159 da Constituição Estadual, que asseguram aos menos favorecidos o direito fundamental à saúde. [...]. 10. Ademais, há informação nos autos de que o NEOCATE é uma fórmula hipoalergênica capaz de atender às necessidades nutricionais de crianças desde o nascimento até os três anos em terapia intensiva neonatal e pediátrica, e que a criança, quando ingere, por exemplo, Aptamil pepti/Pregomin apresenta piora clínica (fls. 18). 11. Também não está havendo a vinculação do fornecimento de marca específica à autora, mas, sim, de fórmula específica que, dentre tantas outras, lhe serve ao tratamento. **12. Por derradeiro, no que diz respeito ao princípio da separação dos poderes, cumpre registrar que é dever do Poder Judiciário a apreciação de lesão ou ameaça a direito (art. 5°, inciso XXXV, da Constituição Federal). Sendo assim, não é violado o princípio da divisão dos poderes, com a determinação de fornecimento de medicamento à pessoa necessitada, pois o direito à saúde não se encontra no âmbito dos atos discricionários (oportunidade e conveniência) da Administração Pública, mas sim se constitui num dever previsto na Constituição Federal de 1988.** [...]. 14. Segurança concedida. Agravo Regimental prejudicado. Decisão unânime. (TJ-PE - MS: 4205129 PE, Grupo de Câmaras de Direito Público, Relator: Alfredo Sérgio Magalhães Jambo, Data de Julgamento: 04/05/2016, Data de Publicação: 18/05/2016). - Destaques nossos.

Veja-se que **os julgados acima ementados se ajustam em absolutamente tudo ao caso em exame**: complemento alimentar semelhante; paciente com alergia à proteína do leite de vaca (APLV); necessidade do tratamento comprovada, indispensável para assegurar melhor qualidade de vida ao requerente; hipossuficiência do postulante; suplemento não previsto em lista oficial, porém, registrado na ANVISA (atendidos, portanto, os requisitos previstos na tese fixada no âmbito do **REsp n° 1.657.156 - RJ** [5], ***muito embora este tenha tratado especificamente de medicamento, e não de dieta alimentar***).

Esse o quadro, a conclusão somente pode ser uma: **pesa sobre o Município de Mirandiba a obrigação de fornecer o complemento alimentar requerido, não podendo se omitir de fazê-lo**, já que lhe cabe assegurar à pessoa carente o mínimo necessário para garantir a sua subsistência com dignidade, pondo-a a salvo de qualquer tipo de negligência, desprezo e discriminação.

Como consabido, é bastante comum que os entes estatais aleguem dificuldades econômicas com o propósito de se furtar às suas obrigações legais, sob o argumento de que estão albergados pela teoria da reserva do possível, "[...] *segundo o qual a garantia de direitos prestacionais depende da disponibilidade de recursos públicos* [...]"[6].

Todavia, a teoria da reserva do possível deve ser analisada com cuidado, sempre atentando para a concreta realidade brasileira, de modo que não é viável admitir sua invocação como escudo intransponível de que se apoderou o Estado para se escusar do cumprimento das necessidades prioritários da população, no caso dos autos, relacionadas à saúde.

De fato, a teoria da reserva do possível é uma construção da jurisprudência da Corte Constitucional alemã e como toda doutrina importada deve ser adaptada à realidade da República Federativa do Brasil.

A respeito do tema, leciona Bernardo Gonçalves Fernandes:

> A chamada cláusula da reserva do possível (*Der Vorbehalt des Möglichen*), que começou a ser alegada a partir da década de 1970, é criação do Tribunal Constitucional alemão e compreende a possibilidade material (financeira) para prestação dos direitos sociais por parte do Estado, uma vez que tais prestações positivas são dependentes de recursos presentes nos cofres públicos. A partir daí, alguns autores vão defender que as aplicações desses recursos e, consequentemente, a implementação de medidas concretizadoras de direitos sociais seria uma questão restrita e limitada à esfera de discricionariedade das decisões governamentais e parlamentares, sintetizadas nos planos de políticas públicas destes e conforme as previsões orçamentárias.
>
> A partir do caso *numerus clausus* decidido pelo Tribunal Federal alemão, [1419] essa visão passou a ser revista, entendendo-se que o direito de acesso ao ensino superior não poderia ficar a

cargo exclusivo das definições internas do Estado, **cabendo ao indivíduo exigir o cumprimento daquilo que minimamente seria razoável exigir-se do Estado – algo nos limites do razoável** [7]. – Destaques nossos.

É inquestionável o fato de que as limitações orçamentárias representam um entrave para a efetivação das políticas públicas. Todavia, a teoria da reserva do possível não pode ser aplicada como desculpa universal para a ineficiência de gestão da administração pública, especialmente no que se refere ao mínimo indispensável à saúde e à vida humana.

De fato, o direito alemão construiu a teoria da reserva do possível para esclarecer que o cidadão só pode requerer do Estado uma prestação que se apresente nos limites do razoável, de tal sorte que o indivíduo atenda aos requisitos objetivos de sua fruição.

Para a Corte Constitucional alemã, os direitos sociais prestacionais estão sujeitos à reserva do possível no sentido daquilo que o indivíduo, de maneira racional, pode esperar da sociedade. Ocorre que a realidade percebida da Alemanha em muito difere da encontrada no Brasil, motivo pelo qual se mostra temerário importar preceitos do direito comparado sem atentar para a situação brasileira.

Ora, na Alemanha, os cidadãos já dispõem de um mínimo de prestações materiais capazes de assegurar existência digna. Por esse motivo, obviamente, o indivíduo não pode exigir do Estado prestações supérfluas, uma vez que isso escaparia do limite do razoável, não sendo exigível que a sociedade arque com esse ônus.

Por outro lado, nos países periféricos, como é o caso do Brasil, a situação é completamente diferente, pois, para a maioria dos cidadãos, as condições mínimas para uma vida digna ainda não foram asseguradas pelo Estado de forma concreta. Assim, qualquer pleito que vise a fomentar uma existência minimamente decente, ou, como é o caso dos autos, possibilitar superior qualidade de vida a JOSÉ, não pode ser encarado como sem razão (supérfluo), pois garantir a dignidade humana é um dos objetivos principais do Estado brasileiro.

Na espécie, como já explanado, está clarividente que a criança interessada necessita do suplemento alimentar pleiteado, para que possa se manter saudável, assim como para impedir o agravamento de seu quadro de saúde.

Ademais, nem se argumente que o Poder Judiciário, ao determinar ao requerido que forneça o complemento alimentar em tela estaria ferindo a separação dos poderes, uma vez que a

conduta do Estado deve se pautar pelo princípio do mínimo existencial, magistralmente explanado por Ana Paula de Barcellos[8] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftn7):

> Em resumo: a limitação de recursos existe e é uma contingência que não se pode ignorar. O intérprete deverá levá-la em conta ao afirmar que algum bem pode ser exigido judicialmente, assim como o magistrado, ao determinar seu fornecimento pelo Estado. Por outro lado, não se pode esquecer que a finalidade do Estado ao obter recursos, para, em seguida, gastá-los sob a forma de obras, prestação de serviços, ou qualquer outra política pública, é exatamente realizar os objetivos fundamentais da Constituição. A meta central das Constituições modernas, e da Carta de 1988 em particular, pode ser resumida, como já exposto, na promoção do bem-estar do homem, cujo ponto de partida está em assegurar as condições de sua própria dignidade, que inclui, além da proteção dos direitos individuais, condições materiais mínimas de existência. Ao apurar os elementos fundamentais dessa dignidade (o mínimo existencial), estar-se-ão estabelecendo exatamente os alvos prioritários dos gastos públicos. Apenas depois de atingi-los é que se poderá discutir, relativamente aos recursos remanescentes, em que outros projetos se deverá investir.

Ademais, a conduta do Estado deve se pautar pelos princípios da legalidade e da eficiência (art. 37, *caput*, da CRFB):

a) Pelo princípio da legalidade, está a Administração Pública sujeita aos mandamentos da lei e às exigências do bem comum, e deles não se pode afastar ou desviar;

b) Pelo princípio da eficiência, exige-se que a Administração Pública atue com presteza, perfeição e rendimento funcional, de modo que a função administrativa não pode ser desempenhada apenas com esteio na legalidade, exigindo-se resultados positivos para o serviço público e satisfatório atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros.

Não se olvide, ainda, que o Estado tem o poder-dever de agir, é dizer, **poder** tem para o agente público o significado de **dever** para com a comunidade e para com os indivíduos, no sentido de que aquele que o detém está sempre na obrigação de exercitá-lo.

Por fim, tampouco restou demonstrada a existência de ofensa ao **princípio da isonomia**, com o atendimento do beneficiário em suposto *detrimento de demais pessoas*. De sorte bem diversa, a *reiteração do descumprimento do dever legal em comento* está a legitimar novos pleitos perante o Poder Judiciário.

Desta forma, a procedência deste pedido é medida que se impõe.

Permite-se, no entanto, ao requerido, por meio do órgão competente, **analisar periodicamente** a eventual melhora e/ou total restabelecimento da infante interessada e/ou desnecessidade de fornecimento do suplemento pleiteado, que **perdurará até que haja expressa recomendação médica/nutricional em sentido contrário**, devendo a parte autora, nos termos do Enunciado nº 2, da 1ª Jornada de Saúde Pública do Conselho Nacional de Justiça[9] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftn8), **apresenta ao órgão competente indicado pelo ente público demandado receita médica <u>semestral</u>**, para continuidade do fornecimento do produto em testilha.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL**, para **CONDENAR** o **MUNICÍPIO DE MIRANDIBA/PE** a fornecer a **JOSÉ MATHEUS GONÇALVES VALÕES suplemento alimentar adequado à sua idade**, suplemento alimentar **Aptamil ProExpert SL**, na quantidade de **08 (oito) latas (de 800g)** mensais, por prazo indeterminado e/ou até ulterior substituição por outro complemento alimentar que se fizer necessário, **sob pena de bloqueio de quantia necessária para o tratamento pelo período de 06 (seis) meses**, até posterior deliberação, ficando a parte autora obrigada à apresentação periódica de laudo médico, a cada 06 (seis) meses, para comprovar a necessidade de manutenção do tratamento. Desse modo, **PONHO FIM À FASE COGNITIVA**, **com resolução do mérito**, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.

Fica **RATIFICADA** a decisão concessiva de tutela provisória de urgência (**ID 147740732**).

Condeno a parte requerida ao pagamento de custas processuais.

<u>Intime-se o Ministério Público a juntar 3 orçamentos dos insumos deferidos para fins de eventual necessidade de bloqueio judicial dos valores.</u>

Na forma do art. 496 do CPC, verbete sumular nº 490[11] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftn10) do STJ

e REsp 1.101.727/PR[12] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftn11) (recurso repetitivo), tratando-se de sentença sujeita ao duplo grau de jurisdição obrigatório, aguarde-se prazo para interposição de recurso voluntário e **REMETAM-SE** os autos em seguida ao Egrégio Tribunal de Justiça de Pernambuco.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Certifique-se, oportunamente, o trânsito em julgado. Após, arquive-se.

Em sendo interposto recurso de **APELAÇÃO**, por não haver mais o juízo de prelibação nesta Instância (art. 1.010 do Código de Processo Civil), **SEM NECESSIDADE DE NOVA CONCLUSÃO**, nos termos do art. 1.010, § 1º, do Código de Processo Civil, **INTIME-SE** o(a) apelado(a) para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias.

Se apresentada apelação adesiva pela parte recorrida (art. 997 do CPC), **INTIME-SE** a parte contrária para contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 1.010, § 2º, do CPC.

Caso sejam apresentadas contrarrazões, em sendo suscitadas preliminares, **INTIME-SE** o apelante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 1.009, § 2º, do Código de Processo Civil, manifeste-se acerca das referidas questões.

Após o prazo, com ou sem resposta, *ex vi* do disposto no § 3º do art. 1.010 do CPC, **REMETAM-SE** os autos ao E. Tribunal de Justiça de Pernambuco, independentemente do juízo de admissibilidade.

Mirandiba, na data da assinatura.

MARCOS JOSÉ DE OLIVEIRA

Juiz Substituto

---

[1] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftnref1) *Proporc e processo: a garantia constitucional da proporcionalidade, a*

legitimação do processo civil e o controle das decisões judiciais. São Paulo: Atlas, 2006, p. 80.

[2] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftnref2) Voto condutor nos autos do RE 195.192-3/RS - Segunda Turma do STF - julgado em 22/02/00.

[3] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftnref3) *Curso de Direito Constitucional Positivo*. 11. ed. São Paulo: Malheiros Editores, 1996, p. 762.

[4] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftnref4) STF, 2ª Turma, Agravo Regimental no Recurso Extraordinário nº 271.286/RS, Relator Ministro Celso de Mello, j. 12.09.2000, DJ 24.11.2000, p. 101.

[5] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftnref5) "**4. TESE PARA FINS DO ART. 1.036 DO CPC/2015** - A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento".

[6] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftnref5) Cláudio Pereira de Souza Neto e Daniel Sarmento. *Direito constitucional - Teoria, história e métodos de trabalho*. Belo Horizonte: Fórum, 2012.

[7] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftnref6) *Curso de direito constitucional*. 3. ed. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2011.

[8] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftnref7) *A Eficácia Jurídica dos Princípios Constitucionais*". Rio de Janeiro: Editora Renovar, 2002, p. 245-246.

[9] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftnref8) Enuncia nº 2: Concedidas medidas judiciais de prestação continuativa, em medida liminar ou definitiva, é necessária a renovação periódica do relatório médico, no prazo legal ou naquele fixado

pelo julgador como razoável, considerada a natureza da enfermidade, de acordo com a legislação sanitária, sob pena de perda de eficácia da medida.

[10] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftnref9) EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016.

[11] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftnref10) "*A dispensa de reexame necessário, quando o valor da condenação ou do direito controvertido for inferior a sessenta salários mínimos, não se aplica a sentenças ilíquidas*".

[12] (https://pje.tjpe.jus.br/1g/downloadBinario.seam#_ftnref11) RECURS ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO. SENTENÇA ILÍQUIDA. CABIMENTO. 1. É obrigatório o reexame da sentença ilíquida proferida contra a União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e as respectivas autarquias e fundações de direito público (Código de Processo Civil, artigo 475, parágrafo 2º). 2. Recurso especial provido. Acórdão sujeito ao procedimento do artigo 543-C do Código de Processo Civil. (STJ, REsp 1101727/PR, Rel. Ministro HAMILTON CARVALHIDO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2009, DJe 03/12/2009).